

次の1から5までの【見解】は、令状によらない差押え等を規定した刑事訴訟法第220条第1項の「逮捕する場合」の解釈に関するものである。後記【発言】は、学生AないしEが、1から5までのいずれかの【見解】を採って、ほかの学生の【見解】について発言したものである。学生AないしEの【見解】は、それぞれ1から5までのうちどれか。なお、同じ【見解】を採っている学生は存しない。

【見 解】

1. 現実逮捕したことを要する。
2. 逮捕に着手したことを要するが、逮捕に成功したかどうかは問わない。
3. 被疑者が現場に存在し、直ちに逮捕に着手し得る状態にあることを要する。
4. 被疑者が現場に存在しなくとも、時間的に接着して逮捕されれば足りる。
5. 被疑者が現場に存在しなくとも、逮捕が見込まれる状態にあれば足り、結果的に逮捕に着手されたかどうかは問わない。

【発 言】

- 学生A. C君の見解は、判例の立場と同じだけれど、それでは、事後的な逮捕の成否により搜索差押えの適法性が左右されることになり、不合理だ。
- 学生B. D君の見解は、私の見解と同様に基準が明確になり、濫用防止に優れている点は理解できるが、刑事訴訟法が「逮捕した場合」ではなく、「逮捕する場合」と規定している文理から離れているという問題がある。
- 学生C. E君の見解は、被疑者がいないまま、結局、最後まで逮捕に着手しなかった場合であっても、「逮捕する場合」に当たるということになるので、文理から離れすぎていて妥当でない。
- 学生D. A君の見解は、逮捕の着手すらない時点から無令状の搜索差押えができることになり、不当だ。
- 学生E. B君の見解は、逮捕の着手に先立って、被疑者らによる証拠の破壊等を防止する必要がある生じることもあるという捜査の実情に対する配慮が欠けていて、硬直的な見解である。

No.80

令状によらない捜索・差押え

正答率

H19-23

正解

[A] 3

[B] 2

[C] 4

[D] 1

[E] 5

71%

学生Aの発言

学生Aの発言から、学生Cの採る見解は、判例の立場と同じであること、事後的な逮捕の成否により捜索差押えの適法性が左右されることになるものであることが分かる。そして、事後的な逮捕の成否を問題とするのは、現実には逮捕がなされたことを要求する見解1と見解4である。また、判例（最大判昭36.6.7、百選A6事件）は、「逮捕する場合」の意義につき、「逮捕との時間的接着を必要とするけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わないものと解すべきであって、このことは、同条（220条）1項1号の規定の趣旨からも窺うことができるのである。したがって、例えば、緊急逮捕のため被疑者方に赴いたところ、被疑者がたまたま他出不在であっても、帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に捜索、差押がなされ、且つ、これと時間的に接着して逮捕がなされる限り、その捜索、差押は、なお、緊急逮捕する場合その現場でなされたとするのを妨げるものではない。」として、見解4の立場に立っている。したがって、学生Aの発言から、学生Cが見解4を採っていることが分かる。

学生Bの発言

「基準が明確になり、濫用防止に優れている」といわれる見解は、逮捕したこと、逮捕に着手したことという客観的基準のみを定立している見解1と見解2である。そのため、これが妥当するという学生B、学生Dは、見解1、見解2のいずれかを採ることが分かる。そして、220条1項柱書が「逮捕した場合」ではなく、「逮捕する場合」と規定している文理から離れすぎていると批判されるのは、逮捕に成功していることを要求する見解1である。したがって、学生Bの発言から、学生Dが見解1、学生Bが見解2を採っていることが分かる。

学生Cの発言

被疑者がいないまま、結局、最後まで逮捕に着手しなかった場合であっても、「逮捕する場合」にあたる点で文理から離れすぎていると批判されるのは、被疑者の現場不存在を許容し、逮捕着手も要件として要求しない見解5である。したがって、学生Cに本記述のように批判される学生Eは、見解5を採っていることが分かる。

学生Dの発言

逮捕の着手すらない時点から無令状での捜索差押えを許容する見解は、見解3、見解4、見解5である。そして、学生Aの発言から、Cが見解4を採ることが分かっており、学生Cの発言から学生Eが見解5を採ることが分かっている。したがって、学生Dの発言から学生Aが見解3を採っていることが分かる。

学生Eの発言

逮捕の着手に先立って、被疑者らによる証拠の破壊等を防止する必要があることもあるという捜査の実情に対する配慮が欠けていて、硬直的であると批判される見解は、必ず逮捕に着手したことを要求する見解1、見解2である。そして、学生Bの発言から、学生Dが見解1、学生Bが見解2を採ることが分かっている。したがって、学生Eの発言から、このことが確認できる。

以上により、学生Aは見解3を、学生Bは見解2を、学生Cは見解4を、学生Dは見解1を、学生Eは見解5を採っている。